

1500493-31.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCEL PANGONI GUERRA

Comarca: Regente Feijó

Foro: Foro de Regente Feijó

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ALEGADA OMISSÃO QUANTO A APRECIACÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ALEGA PARA OBSTAR A INCIDÊNCIA CDO REDUTOR MENCIONADA PELA JUÍZA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - Impõe-se o reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, porquanto a apelante preenche todos os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Regente Feijó

Foro de Regente Feijó

Vara Única

Rua: Carlos Beltrame, 10 - Portal do Sol

CEP: 19570-000 - Regente Feijo - SP

Telefone: (18) 3279-1555 - E-mail: regfeijo@tjsp.jus.br

1500493-31.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500493-31.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEYTON MESSIAS ALVES DE CARVALHO

CONCLUSÃO: Em 04/10/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito desta Comarca de Regente Feijó. Eu, assistente judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCEL PANGONI GUERRA

VISTOS.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de CLEYTON MESSIAS ALVES DE CARVALHO, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta da denúncia, no dia 10 de junho de 2022, por volta de 23h20min, na Rodovia SP 483, KM 27, na cidade de Taciba, nesta comarca de Regente Feijó, o réu, qualificado às fls.13 e 25, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a entrega a consumo de terceiros, 150 gramas de cocaína, acondicionada em um tijolo, conforme auto de exibição e apreensão de fls.17/18 e laudo pericial acostado em fls.30/32, constando na exordial que o entorpecente seria entregue a uma pessoa no Município de Narandiba/SP, sendo que o acusado estava vindo da cidade de Londrina/PR, ou seja, que o tráfico de drogas se deu entre Estados da Federação. Notificado (fl. 100), o réu, por meio de defensor constituído (fls. 48 c/c

170/171), apresentou defesa preliminar (fls. 105/107).

A denúncia foi recebida em 15 de julho de 2022 (fls. 108/111).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, tendo o réu sido interrogado (fls. 191/193).

Em memoriais, o Ministério Público postulou a procedência da acusação (fls. 214/221).

A defesa, por sua vez, em memoriais, pediu pela parcial procedência da acusação, afastando-se a causa de aumento de pena e reconhecendo-se a incidência da atenuante referente à confissão e a causa de diminuição de pena constante no § 4º do artigo 33, da Lei 11343/06 (fls. 228/238).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade e a autoria delitivas ficaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito (01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 14/18), pelos documentos de fls. 35/37, pelos laudos periciais de fls. 30/32, fls. 158/169 e fls. 206/208, bem como pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Em juízo, a testemunha Cesar Alves de Conceição, policial militar, narrou que na data dos fatos estava com sua equipe em local na divisa com o Estado do Paraná, quando foi avistado um veículo que, ao perceber a presença da viatura, desviou e adentrou um canavial, que dava acesso à cidade vizinha. Explicou que, quando abordaram o réu, foi encontrado com ele uma porção de drogas no bolso de sua blusa. Contou que, ao ser indagado, o acusado disse que era a terceira vez que estava entregando o entorpecente na cidade de Narandiba e que receberia a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais) pelo serviço. Esclareceu ainda que, após a abordagem, encaminharam o réu à Delegacia de Polícia de Taciba. Não soube dizer o valor de mercado da quantidade de droga apreendida com o réu. Não soube informar a quilometragem entre o local em que o réu foi preso até a cidade de Londrina. Reafirmou que o réu lhe disse que receberia a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais) para levar a droga até Narandiba. Negou ter sido feita investigação para o fim de comprovar que o réu trazia as drogas de Londrina.

A testemunha Ricardo Santos de Oliveira, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento na divisa entre os estados de Paraná e São Paulo e, em dado momento, foi avistado um veículo que, ao perceber a viatura, adentrou em um canavial. Salientou que, ao ser abordado, foi encontrado o entorpecente com o indivíduo, no bolso direito de sua blusa. Não soube dizer o valor de mercado da quantidade de droga apreendida com o réu. Relatou que o réu disse que estava levando a droga para a cidade de Narandiba e que receberia R\$ 1.000,00 (mil reais) por isso. Disse não saber a quilometragem entre as cidades de Londrina e Narandiba. Negou saber com certeza se a droga saiu de Londrina.

Interrogado, o réu narrou que tinha o aniversário de um parente em São Paulo e comentou com alguns colegas que iria, quando um deles pediu para que ele fizesse a entrega de uma mercadoria na cidade de Narandiba/SP, após pegá-la no município de Nantes/SP, em troca da quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais). Declarou que precisava desse dinheiro, pois a pensão do filho estava atrasada, correndo o risco de ser preso e que tinha aluguel para pagar e que faltava coisas em casa, vez que os empregos de motoboy e no lava-jato não estavam rendendo muito dinheiro. Disse que o referido colega não especificou o conteúdo da mercadoria e que esta estava embalada. Afirmou que apenas aceitou o serviço em razão da difícil situação financeira pela qual estava passando. Explicou que, quando os policiais o abordaram e lhe perguntaram o que era a mercadoria, não soube dizer, vindo a descobrir que se tratava de droga apenas quando o policial abriu a embalagem. Reafirmou que pegou a droga em Nantes e não em Londrina. Disse estar arrependido e que aceitou o serviço de transportar o embrulho apenas porque precisava do dinheiro "eu fui pelo dinheiro, eu não sabia mais o que fazer, a minha ex-mulher me colocou na Justiça. Eu corria o risco de ser preso por não pagar a pensão do meu filho". Relatou que a droga estava em seu bolso quando os policiais o abordaram, salientando que, se soubesse que se tratava de drogas, as teria escondido. Reafirmou estar arrependido.

Por fim, reiterou ter pegado a droga na cidade de Nantes/SP.

Pois bem.

De início, pontue-se que o fato de os policiais terem atuado na ocorrência não implica impedimento para a tomada de seus depoimentos em juízo, sob compromisso.

Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Aliás, falando-se em policiais, civis ou militares, mesmo guardas civis, há de se lembrar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto, absurdo, de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos, judiciais que sejam, prestados por policiais, sejam civis ou militares, mesmo guardas civis, porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada (...)” (TJ-SP – Apelação Criminal n. 3001363-88.2013.8.26.0333, Rel. Des. Airton Vieira, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, 10/12/2015).

Os depoimentos prestados pelos policiais gozam de credibilidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas. No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento das versões apresentadas pelos policiais, harmônica com outros elementos probatórios colacionados.

Feita a ressalva acima, pelo que se extrai do arcabouço probatório amealhado, inexistem dúvidas de que o réu praticou o crime que ora lhe é imputado.

Em termos, pelo contido nos autos, conclui-se que, de fato, o réu trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a entrega a consumo de terceiros, 150 gramas de cocaína, acondicionada em um tijolo, tendo o crime sido cometido entre estados da Federação, porquanto a droga estava sendo transportada do Estado do Paraná (cidade de Londrina/PR) para o Estado de São Paulo (Narandiba/SP).

O auto de exibição e apreensão (fls. 14/18) e os laudo periciais de fls. 30/32 e fls. 206/208 c/c fotografias de fls. 35/37 bem esclarecem a quantidade da droga apreendida (150 gramas, acondicionada em um tijolo), a qual se trata de cocaína e que estava, conforme versão das testemunhas, dentro do bolso da blusa de CLEYTON, droga com ele encontrada quando revistado durante a abordagem policial, inexistindo dúvida quanto à autoria do réu, bem como que o sobredito entorpecente foi transportado do Estado do Paraná (cidade de Londrina/PR) para o Estado de São Paulo (Narandiba/SP).

A propósito, em juízo, os policiais foram uníssonos em aduzir que o réu foi abordado na divisa entre os Estados do Paraná e de São Paulo e que aquele, ao avistar o policiamento, adentrou um canavial, tendo o entorpecente sido encontrado no bolso da blusa e que o acusado, ainda, disse que entregaria o entorpecente na cidade de Narandiba/SP e que receberia R\$ 1.000,00 pelo transporte, de modo que, portanto, evidente que o acusado, vindo do Estado do Paraná, adentrou este Estado (São Paulo), trazendo consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a entrega a consumo de terceiros, o entorpecente apreendido.

Ora, a versão do réu, apresentada em juízo, está isolada nos autos, estando ausente de qualquer lastro probatório.

Ouvido em juízo, CLEYTON sequer apresentou maior detalhe de quem, então, teria pego o entorpecente na cidade de Nantes/SP.

Não interfere no desfecho do feito a alegação do acusado de não saber o que se tratava o embrulho que trazia consigo, porquanto evidente que sabia que se tratava de material de natureza ilícita, pois, do contrário, não teria motivo para, assim que avistada a viatura, ter tentado se evadir da abordagem e adentrado o canavial.

E notório que o acusado empreendeu fuga carregando consigo o entorpecente com o intuito de, pois nada mais de ilícito sendo encontrado no veículo que conduzia. Aliás, ainda que não soubesse o acusado da natureza ilícita do material, não estaria afastada a sua responsabilidade criminal sob a alegação de que não sabia que se tratava de entorpecente o que trazia consigo, uma vez que não se poderia admitir que o réu, de propósito, se beneficiasse ao se colocar em situação de “cegueira deliberada”, de modo que, portanto, seria a hipótese de aplicação da teoria da cegueira deliberada (willful blindness doctrine ou teoria das instruções da avestruz), isto é, de o réu se colocar deliberadamente em condições de ignorância proposital a fim de incorrer deliberadamente em erro de tipo, de modo a tentar furtar-se à responsabilidade criminal que deve recair sobre ele, o que, frise-se, não vinga.

Sobre o tema, lecionam André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves:

Para dizer que alguém praticou uma conduta reprovável, é preciso que se possa exigir dessa pessoa, na situação em que ela se encontrava, uma conduta diversa. Reinhard Frank foi pioneiro na sistematização desse critério, inserindo-o dentro da culpabilidade. O autor estabeleceu como premissa fundamental a de que só se pode impor pena ao autor de um injusto (fato típico e antijurídico) quando se demonstrar ter sido seu comportamento reprovável. Para tanto, é necessário que dele se possa exigir conduta diversa, ou seja, que na situação em que o fato foi cometido, seja lícito concluir que o agente possuía uma alternativa válida de conduta. Se, por outro lado, verificar-se que as condições exteriores não lhe davam outra saída senão agir daquela maneira, seu ato não poderá ser tido como censurável. A ausência da censurabilidade acarreta a falta de culpabilidade e, desta forma, isenta-o de pena. Esse raciocínio funda-se no livre-arbítrio, isto é, na tese de que se deve punir alguém quando o ilícito resultou de uma livre opção; sem esta liberdade de escolha entre agir ou não agir criminosamente, não será justo aplicar a pena criminal (ESTEFAM, A.; GONÇALVES, V. E. R. Direito penal esquematizado: parte geral. 5 Ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

Repise-se, porém, que no cenário em tela era nítido que o réu sabia ou desconfiava da natureza ilícita de sua conduta.

Ademais, conforme exposto pelo próprio réu, receberia ele a quantia de R\$1.000,00 (mil reais) para transportar “o embrulho” até a cidade de Narandiba, oferta, dessa natureza, certamente relativa a atividades ilícitas.

Nem se cogite, no caso em tela, a inexigibilidade de conduta diversa.

Fato é que, para classificar a conduta de determinado agente como reprovável, é imprescindível que se possa exigir deste indivíduo, naquela situação fática, conduta diversa, cenário dos autos, porquanto plenamente possível se concluir o caráter ilícito do transporte/trazer consigo a droga, realizado pelo réu, tendo em vista as características de sua “contratação”, ou seja, que não foi forçado a praticar a conduta em análise, mas que a aceitou com a finalidade de, de maneira mais fácil e rapidamente, obter recurso financeiro.

Sobre o tema, lecionam André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves:

Para dizer que alguém praticou uma conduta reprovável, é preciso que se possa exigir dessa pessoa, na situação em que ela se encontrava, uma conduta diversa. Reinhard Frank foi pioneiro na sistematização desse critério, inserindo-o dentro da culpabilidade. O autor estabeleceu como premissa fundamental a de que só se pode impor pena ao autor de um injusto (fato típico e antijurídico) quando se demonstrar ter sido seu comportamento reprovável. Para tanto, é necessário que dele se possa exigir conduta diversa, ou seja, que na situação em que o fato foi cometido, seja lícito concluir que o agente possuía uma alternativa válida de conduta. Se, por outro lado, verificar-se que as condições exteriores não lhe davam outra saída senão agir daquela maneira, seu ato não poderá ser tido como censurável. A ausência da censurabilidade acarreta a falta de culpabilidade e, desta forma, isenta-o de pena. Esse raciocínio funda-se no livre-arbítrio, isto é, na tese de que se deve punir alguém quando o ilícito resultou de uma livre opção; sem esta liberdade de escolha entre agir ou não agir criminosamente, não será justo aplicar a pena criminal (ESTEFAM, A.; GONÇALVES, V. E. R. Direito penal esquematizado: parte

geral. 5 Ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

Outrossim, menos ainda de prosperar eventual tese de estado de necessidade.

É absolutamente inaceitável considerar que circunstâncias de dificuldade financeira sejam aptas a autorizar condutas criminosas, sob pena de desencadear uma alarmante situação de insegurança jurídica e estremecer o convívio social, principalmente em localidades onde há concentração de pobreza.

Ademais, o tráfico de entorpecentes engendra infortúnios à população, de maneira geral, e ao Estado, vez que a distribuição de drogas afeta não só a vida do viciado e o convívio social, causando danos muitas vezes irreversíveis, como também o próprio Estado, em virtude dos prejuízos acarretados à saúde pública, bem penal tutelado pelo tipo.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Tráfico de drogas. 16,07g de cocaína. 1. Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. 2. Validade dos depoimentos prestados pelos policiais, que se mostram coerentes e harmônicos. 3. Quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, apreensão do dinheiro, indicam o intuito de mercancia. Impossibilidade de desclassificação para a infração do artigo 28, da Lei 11.343/06. 4. Inexigibilidade de conduta diversa. Alegações atinentes às dificuldades financeiras do réu para satisfação das necessidades vitais próprias e de sua família não foram comprovadas pela Defesa, ônus imposto por expressa previsão no artigo 156 do CPP. Situação de dificuldades pelas quais a Defesa alega que o réu passava deve ser resolvida por meios idôneos. 5. Reprimenda reduzida. Pena-base fixada no mínimo legal. Aplicação do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11/343/06 na fração máxima de dois terços. Pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta) dias-multa, no mínimo legal. 6. Fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", tendo em vista a quantidade de pena fixada e o tempo de prisão cautelar. 7. Conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e na prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo. Recurso parcialmente provido" (TJSP; Apelação 0045313-74.2012.8.26.0224; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 4ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2014; Data de Registro: 22/01/2015).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. (...) 4. A existência do tipo penal reflete a implícita reprovação da sociedade à conduta desvalorada pela lei, no caso, o tráfico de drogas, que tem como bem jurídico tutelado a saúde pública. Presume-se, portanto, que o cidadão deve agir de forma diversa dos inúmeros verbos elencados no preceito primário do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06. E o ônus de provar a inexigibilidade de conduta diversa, apta a afastar a reprovação que implicitamente compõe o tipo, é, indiscutivelmente, da ré. 5. Não se acolhe a tese da defesa no sentido de aplicação das chamadas "teoria da co-culpabilidade" e da "culpabilidade funcional", teorias modernistas, que se tenta inserir no Direito Penal brasileiro, fundadas no sistema funcionalista do crime, na sua vertente racional-teleológica, também conhecida como "funcionalismo moderado". Tratam-se de teorias extremamente garantistas, que visam mais a beneficiar, e mesmo fomentar, a prática de novos crimes, não impingindo as devidas punições aos agentes criminosos, como forma de repelir novas práticas delitivas. Desta feita, não se pode conferir validade à pobreza, baixa escolaridade ou descaso do Estado para se justificar e permitir a prática de condutas penalmente tipificadas (...)" (TJSP;

Apelação 0003035-82.2014.8.26.0161; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Diadema - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/11/2015).

De se salientar, ademais, que, em que pesem as alegações do réu de que teria pegado o entorpecente na cidade de Nantes, dentro do estado de São Paulo, tal versão, consoante já aduzido, está ilhada e em discordância em relação às demais provas, aliás, firmes, que foram colhidas.

A propósito, plenamente economicamente viável ao acusado a realização do transporte do entorpecente entre as cidades de Londrina/PR e Narandiba/SP, pelo valor de R\$ 1.000,00, porquanto trata-se de trajeto, cuja soma das distâncias de ida e volta, não ultrapassam 300km.

Desta feita, pelo contido nos autos, comprovado que o tráfico foi praticado entre estados da Federação (Paraná e São Paulo), incidente, in casu, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Assim, inexistindo causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena, bem como estando demonstradas a materialidade e a autoria do crime, a condenação é medida de rigor. Passo, pois, à individualização da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, analiso as circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (dolo inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado é primário - fls. 42 c/c 92/94 e 184/185); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (mais graves do que o usual, porquanto o delito foi cometido em caráter interestadual, o que será considerado na terceira fase da dosimetria); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar); natureza e quantidade do entorpecente (foi apreendida quantidade de cocaína passível de fracionamento ou de geração de considerável entorpecente crack, tratando-se de entorpecente de poder devastador muito maior do que, por exemplo, maconha, tal circunstância será considerada na terceira fase da dosimetria da pena para modular a aplicação da causa de diminuição específica prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos). Destarte, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo penal, ausentes circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante referente à confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e Súmula 545, STJ). Ocorre que a pena nesta fase da dosimetria não pode atingir patamar abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ), de forma que se mantém a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na derradeira fase do cálculo penal, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, uma vez que ficou demonstrado que o transporte da droga tinha caráter interestadual, porquanto envolveu dois Estados da Federação (Paraná e São Paulo). Assim, majoro a reprimenda à razão de 1/6 (um sexto), totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ainda na terceira fase do cálculo penal, presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

O escopo do legislador ao estabelecer o privilégio foi de diferenciar o traficante habitual do neófito, beneficiando o segundo com uma causa especial de diminuição de pena. Bem por isso, para a aplicação do redutor, é necessário que o agente seja primário, ostente bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, exatamente como ocorre no caso em tela.

A condição de "mula", por si só, não é apta a afastar a incidência do benefício, haja vista que, somando-se à primariedade, bons antecedentes e ausência de prova quanto à integração em organização criminosa, não é um indicador de que o agente se dedique a atividades criminosas.

Inegável que a atuação como "mula" é vital para a disseminação de drogas pelo país, contudo não constitui uma prova de envolvimento habitual e permanente do réu com

associação criminosa, porquanto é muito comum que o primeiro contato com o mundo do crime se dê através do transporte de drogas para terceiros desconhecidos. Dessa maneira, a qualidade de "mula", per se, não altera a condição de "traficante de primeira viagem", de forma que não justifica o afastamento da causa específica de diminuição de pena por não descaracterizar nenhum dos requisitos subjetivos exigidos pelo § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, já decidiram o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o C. Superior Tribunal de Justiça e o Pretório Excelso:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Maconha. Autoria e materialidade do crime bem demonstradas. Apreensão de relevante quantidade de entorpecentes com o réu, que confessou em Juízo transportá-los em viagem interestadual. Majorante. Art. 40, V, da Lei nº 11.343/06. Afastamento. Impossibilidade. Droga que era transportada de São Paulo com destino a Minas Gerais, pouco importando a não transposição da fronteira entre os Estados. Condenação mantida. Penas que comportam pequeno ajuste, para que a básica seja estabelecida no mínimo legal. Manutenção, por outro lado, do mínimo redutor decorrente do "tráfico privilegiado" e da fixação do regime inicial fechado. Parcial provimento do recurso" (TJSP; Apelação 0000747-51.2017.8.26.0099; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/09/2018; Data de Registro: 21/09/2018).

"PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ALEGADA OMISSÃO QUANTO A APRECIACÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ALEGA PARA OBSTAR A INCIDÊNCIA CDO REDUTOR MENCIONADA PELA JUÍZA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - Impõe-se o reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, porquanto a apelante preenche todos os requisitos estabelecidos em lei, na medida em que é primária, não possui antecedentes maculados, além de não haver provas nos autos de que esta se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa. Embargos acolhidos" (TJSP; Embargos de Declaração 0000134-62.2016.8.26.0585; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Epitácio - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. SÚMULA 7/STJ. CONTRIBUIÇÃO DO AGENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NA CONDIÇÃO DE MULA. APLICAÇÃO DO REDUTOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. No caso, conforme se extrai dos excertos, o Tribunal de origem, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, concluiu motivadamente pela aplicação do redutor no patamar de 1/3, tendo em vista que a atuação da ré era típica de 'mulas do tráfico', embora tenha sido apreendida com grande quantidade de drogas (33 kg de maconha). 3. O atual entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria é no sentido de que a simples atuação como "mula", por si só, não induz que o réu integre organização criminosa, de forma estável e permanente, não constituindo, portanto, fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor em sua totalidade, tratando-se de meras ilações, presunções ou conjecturas, até porque pode se tratar de recrutamento único e eventual (Precedentes.) 4. Agravo regimental não provido" (STJ - 5ª Turma, AgRg no REsp 1776471/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 13/12/2018).

"Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (2.596 g de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). "Mula". Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. Inexistência de prova de que o paciente integre organização criminosa. Impossibilidade de negar a incidência da causa de diminuição de pena com base em ilações ou conjecturas. Precedentes. Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de

cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. 2. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que o réu integre organização criminosa. Precedentes. 3. O exercício da função de "mula", embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. Precedentes. 4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria. 5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto). 6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa" (STF- 2ª Turma, HC 134597, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 28/06/2016).

Desta feita, tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, bem como inexistentes provas seguras no sentido que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, necessária se faz a aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Em relação ao quantum, haja vista que foi apreendida quantidade de cocaína passível de fracionamento ou de geração de considerável entorpecente crack, tratando-se de entorpecente de poder devastador muito maior do que, por exemplo, maconha, tal circunstância deve ser considerada para a modulação da aplicação da causa de diminuição específica prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, de modo que vislumbro que o redutor deve ser aplicado à razão mínima, ou seja, de 1/6 (um sexto), totalizando a pena em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Com fulcro no art. 33, § 2º, b, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Pelo montante de pena fixado, o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44, inciso I, do CP). Também, pela mesma razão, não cumpre os requisitos para a concessão do sursis (art. 77, caput, do CP).

- Da detração:

Por força do § 2º do art. 387 do CPP, com a nova redação dada pela Lei nº 12.736/12, em linha de princípio, deve o juiz da esfera de conhecimento, após fixar a pena definitiva e o regime inaugural de cumprimento da expiação, dedicar novo capítulo na sentença condenatória para a análise de eventual progressão de regime. Entrementes, o desconto imposto pela novel legislação deve ser ponderado à luz das regras insculpidas na Lei de Execução Penal, e não como mero cálculo aritmético isolado, sob pena de permitir à condenada uma progressão de regime imprópria, ou seja, com lapsos temporais reduzidos e desconhecimento completo de seu mérito pessoal, em total arrepio às regras existentes, as quais, diga-se de passagem, não foram revogadas.

Em outras palavras, o período de detração para fins de progressão de regime prisional já na fase de conhecimento, além de corresponder às frações legalmente estabelecidas, não tem o condão de desautorizar o juiz na aferição do mérito da sentenciada, o que será verificado pelo atestado de comportamento carcerário e, em alguns casos, de parecer criminológico, notadamente quando houver necessidade de um exame mais acurado sobre o progresso de ressocialização.

Cumpra registrar que a inovação legislativa instituiu uma interação entre as jurisdições penais de conhecimento e executiva, propiciando ao magistrado da primeira etapa de cognição o reconhecimento de eventual progressão de regime prisional, desde que presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos na lei de regência.

Ou seja, para a progressão de regime há uma série de fatores que devem ser computados. E, no presente caso, ainda que tivesse a ré cumprido o requisito objetivo (temporal), a análise de mérito, pela própria natureza e gravidade do delito perpetrado, não prescinde, no entender deste Magistrado, da prévia submissão de análise dos elementos subjetivos.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória, o que faço para CONDENAR o réu CLEYTON MESSIAS ALVES DE CARVALHO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, fixados estes no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso nas penas do artigo 33, §4º, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

O réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e praticou crime gravíssimo, equiparado a hediondo. A presente sentença condenatória torna ainda mais veemente o fumus boni juris para a manutenção da prisão cautelar do acusado.

Consoante já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

"Inaplicável, a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória (RHC 177 - RJ- 5! Cfm. do STJ, v.u., rel. M. Assis Toledo, DJU, de 30.10.89), pois, seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar, viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais" (RT 504/339).

Ainda, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de sorte que ainda está presente o periculum libertatis.

Assim, INDEFIRO ao réu o direito de apelar em liberdade, devendo, caso queira recorrer, fazê-lo custodiado. Recomende-se-o na prisão em que se encontra.

Todavia, haja vista o regime inicial ora imposto (semiaberto), necessária a imediata adequação da execução provisória.

Oficie-se, solicitando a imediata adequação da execução provisória.

Transitada em julgado a sentença:

- a) Notifique-se o réu para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, consoante o artigo 50, caput, do Código Penal;
- b) Inclua-se o registro da condenação no Sistema Informatizado Oficial, porquanto o lançamento do nome do réu no rol dos culpados é providência desnecessária, ante a revogação do artigo 393, inciso II, do Código de Processo Penal, pelo artigo 4º da Lei nº 12.403/2011, e em vista do Provimento CGJ 33/2010, que extinguiu o Livro Rol dos Culpados;
- c) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com cópia desta decisão, para suspensão de seus direitos políticos, conforme artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- d) Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se a condenação do réu;
- e) Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme artigo 105 da Lei nº 7.210/84.
- f) Decreto o perdimento dos bens apreendidos (dinheiro, veículo automotor e aparelhos celulares apreendidos com o réu - cf. auto de exibição e apreensão às fls. 14/18), porquanto utilizados para a prática delitiva - dinheiro utilizado para o custeio do transporte da droga até o destino final, sendo o veículo utilizado para o transporte da droga e os aparelhos celulares utilizados para a comunicação,

pelo menos, acerca do destino final do entorpecente.

Com o trânsito em julgado, encaminhe-se ofício à SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no artigo 63, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Custas ex legis.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Regente Feijó, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA